

1502644-92.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes.

Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado:

inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

1502644-92.2019.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502644-92.2019.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADAILTON MACHADO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia em face de ADAILTON MACHADO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 04 de novembro de 2019, por volta das 16h15, na Rua Analandia, 112, Município de Cajamar, ADAILTON MACHADO DE OLIVEIRA, trazia consigo, para fins de traficância, 25 porções de cocaína, 4 porções de crack e 17 porções de maconha, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Laudo de exame químico de entorpecente acostado (f. 103-105).

A denúncia foi recebida em 21/11/2016 (f. 93-94), o réu foi regularmente citado (f. 101) e ofereceu defesa prévia (f. 110-112).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (f. 113-114), prosseguiu-se à fase instrutória, momento em que foram ouvidas testemunhas.

O réu não foi intimado para audiência, malgrado tenha sido realizada tentativa de intimação no endereço informado nos autos (fl. 102), sendo-lhe, por conseguinte, aplicado o art. 367 do CPP.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Ministério Público e Defesa manifestaram-se em alegações finais orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de ADAILTON MACHADO DE OLIVEIRA pela prática do fato delituoso disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De fato, assiste razão ao Ministério Público.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência (f. 5-7), auto de exibição e apreensão (f. 8), auto de constatação da natureza tóxica (f. 10) e laudo pericial químico de entorpecente (f. 103-105), que atestou que as substâncias encontradas se tratavam de cocaína e THC, que são de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado ADAILTON MACHADO DE OLIVEIRA.

Inquirida, a testemunha ANTONIO ARAUJO SOUZA JÚNIOR, guarda municipal, disse que em patrulhamento pelo local dos fatos, que é área conhecida pelo tráfico de drogas, depararam-se com um indivíduo carregando uma sacola na mão. Ao perceber a presença da viatura, dispensou a sacola e seguiu andando. Efetuada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém recuperaram a sacola e constataram a existência de entorpecentes. Ao ser indagado, disse que a droga não era sua, mas pertencia a um traficante. Entretanto, relatou que havia vendido as drogas por duas vezes, em substituição ao traficante, a quem auxiliava como "olheiro". Não se recorda da quantidade e da natureza dos entorpecentes. Afirmou que o acusado confessou que estava traficando há 4 dias. Não o conhecia previamente. Não se lembra da cor da roupa do acusado. O abordado não mencionou o nome do traficante, que substituiu em função de ter ido ao banheiro.

A testemunha MARCEL AUGUSTO SENERINI, guarda municipal, relatou que apreenderam indivíduo que carregava sacola amarela. Efetuada a abordagem, puderam perceber que havia uma série de entorpecentes dentro da sacola. Não se lembra da quantidade. Recorda-se que havia cocaína, crack e maconha. Afirmou que atuava como "olheiro" e que o traficante havia ido ao banheiro, motivo pelo qual praticou atos de traficância. O réu afirmou que havia vendido em duas ou três oportunidades. O réu teria afirmado que estava na traficância há 4 ou 5 dias. O local é conhecido como ponto de vendas de drogas. Não se recorda do acusado. Não se lembra da cor da roupa que o réu usava e se ele teria dito o valor da diária para a atuação como "olheiro".

Interrogado, o acusado ADAILTON MACHADO DE OLIVEIRA confessou a prática do crime perante a Autoridade Policial (fl. 04).

Tem-se que a procedência da imputação é de rigor e deflui do conjunto probatório coligido, em especial do depoimento das testemunhas que efetuaram a diligência de apreensão das substâncias.

Inicialmente, não há porque se desconfiar da palavra dos guardas municipais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato de o agente manter em depósito e trazer consigo drogas para entrega e consumo de terceiros, o que ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Ademais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irre realidade.

Nada indica que os policiais tenham criado uma situação para acusar falsamente o acusado. A presunção iuris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.

Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia. O fato de não terem os guardas municipais se lembrado de algumas especificidades relativas ao episódio, como da cor da roupa

do acusado no momento da abordagem, em nada infirma a prova produzida, sobretudo dado o lapso temporal transcorrido entre a data do delito - 04 de novembro de 2019 - e a da audiência.

Com efeito, os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo estão tranquilamente comprovados nos autos: a quantidade de entorpecente (25 porções de cocaína, 4 porções de crack e 17 porções de maconha); o modo de acondicionamento (invólucros plásticos, embalados individualmente e prontos para o comércio); o local onde se deram os fatos (conhecido ponto de tráfico de drogas); revelam que se tratava sim da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

E pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, apesar de tecnicamente primário, o comércio de substância altamente letal ao ser humano (crack) impõe uma elevação nas penas bases, no montante de 1/6, resultando-se em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, motivo pelo qual mantenho a reprimenda no patamar anterior.

Na terceira fase de cálculo penal, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é primário, portador de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

No entanto, para evitar bis in idem deixo de valorar a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos. Nesse aspecto: "Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência. Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio." (Brasília - residência -, 1º de abril de 2014. Ministro MARCO AURÉLIO).

Desta feita, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3, totalizando 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Tendo em vista que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nesse ponto, ressalto recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada não possui natureza hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes

privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida." (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, verifico que o regime inicial aberto se mostra mais adequado, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, da primariedade e conduta social e personalidade favoráveis, não obstante a alta lesividade da substância entorpecente apreendida.

E, pelos mesmos motivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 2 salários-mínimos vigentes, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia para CONDENAR ADAILTON MACHADO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas; substituída a primeira por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 2 salários mínimos vigentes, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Não houve alteração fática que justifique a imposição de prisão preventiva (artigos 387, § 1º, e 312, ambos do CPP), de forma que concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante à inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de reparação dos danos causados pela infração e diante da ausência de pedido.

Condeno o réu nas custas processuais, ressalvada a hipótese de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC.

Com o cumprimento do mandado de prisão, expeça-se a guia de recolhimento provisória, bem como carta de guia.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento definitiva;

Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários e bens apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06;

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que, após o trânsito em julgado, também deverá ser incinerada;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob

pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido, expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);

Arbitre os honorários do(a) defensor(a) do(a) acusado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminha-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Cajamar, 7 de abril de 2022.